

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제1절 공동소송>

I. 공동소송의 개관

1. 의의

(1) 개념

- 공동소송이란 하나의 소송절차에 여러 사람의 원고 또는 여러 사람의 피고가 관여하는 소송 형태를 의미한다. 이는 주관적 병합(객관적 병합은 청구의 병합을 말한다)이라고도 불리며, 단일한 소송계속 내에서 다수의 당사자가 대립하는 구조를 가진다.

(2) 인정취지

- 동일한 사실관계나 법률관계에서 비롯된 여러 개의 청구를 하나의 절차에서 심리함으로써 재판의 중복을 피하고 소송비용을 절감하는 소송경제의 도모를 목적으로 한다. 또한, 동일한 사안에 대해 서로 모순되는 판결이 나오는 것을 방지하여 재판의 신뢰를 높이는 효과가 있다.

(3) 구별

- 공동소송은 소송대리인이나 소송수행권자와 구별된다. 공동소송인은 각자가 당사자로서의 지위를 가지며, 판결의 효력 또한 원칙적으로 개별 당사자에게 미친다.

2. 공동소송의 일반요건[민소법 제65조, 제253조]

- 공동소송이 성립하기 위해서는 주관적 요건과 객관적 요건을 모두 갖추어야 한다. 민사소송법 제65조 전단은 소송목적이 되는 권리나 의무가 여러 사람에게 공통되거나 동일한 사실상·법률상 원인에 바탕을 둔 경우를 규정하고, 후단은 소송목적이 되는 권리나 의무가 같은 종류이며 사실상·법률상 같은 종류의 원인에 바탕을 둔 경우를 규정한다. 또한, 제253조에 따라 여러 개의 청구가 같은 종류의 소송절차를 따라야 하며 공통의 관할권이 존재해야 한다.

II. 통상의 공동소송

1. 통상공동소송의 의의

- 통상공동소송이란 공동소송인 사이에 소송목적이 법률상 합일적으로 확정될 필요가 없는 공동소송을 말한다. 민사소송법 제65조의 요건을 갖추었으나 필수적 공동소송에 해당하지 않는 모든 경우가 이에 속한다.

2. 공동소송인 독립의 원칙

(1) 의의

- 공동소송인 1인의 소송행위나 1인에 대한 상대방의 소송행위, 1인에게 발생한 소송사항이 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 않는다는 원칙이다.

(2) 내용

- 첫째, 소송진행의 독립이다. 1인에 대한 소송절차의 중단이나 중지는 다른 공동소송인에게 영향을 주지 않는다. 둘째, 소송자료의 독립이다. 1인의 자백이나 증거제출은 다른 인원의 소송자료로 활용되지 않는다. 셋째, 본안결정의 독립이다. 법원은 공동소송인별로 서로 다른 내용의 판결을 내릴 수 있다.

3. 공동소송인 독립의 원칙의 수정

(1) 수정의 원리

- 통상공동소송이라 하더라도 재판의 모순을 방지하고 심리의 효율을 높이기 위해 독립의 원칙을 완화할 필요가 있다.

(2) 주장공통의 원칙

- 공동소송인 1인이 제출한 유리한 주장이 다른 공동소송인에게도 효력을 미치는지에 대해, 우리 판례는 통상공동소송에서는 이를 부정한다. 다만, 변론주의 원칙상 법원이 전체 기록을 토대로 사실을 확정하는 과정에서 간접적으로 반영될 여지는 있다.

(3) 증거공통의 원칙

- 공동소송인 1인이 제출한 증거는 다른 공동소송인과의 관계에서도 사실인정의 자료로 삼을 수 있다는 원칙이다. 판례는 증거자료의 불가분성을 근거로 통상공동소송에서도 증거공통의 원칙을 인정한다.

III. 필수적 공동소송

1. 의의

- 공동소송인 사이에 소송목적이 법률상 합일적으로 확정될 필요가 있는 공동소송을 말한다. 이는 다시 법률상 당사자 전원이 함께 소를 제기하거나 제기당해야만 하는 고유필수적 공동소송과, 각자가 소를 제기할 수 있으나 일단 공동소송이 되면 합일확정이 필요한 유사필수적 공동소송으로 나뉜다.

2. 고유필수적 공동소송

(1) 의의

- 소송물의 관리처분권이 공동차주나 공동상속인처럼 공동당사자 전원에게 귀속되어, 전원이 합쳐서 소송을 수행하지 않으면 부적법하게 되는 경우이다.

(2) 인정 여부

- 합유재산에 관한 소송이나 공동상속재산에 대한 공유물분할청구 등이 이에 해당한다. 다만, 판례는 공유관계에서의 보존행위 등은 고유필수적 공동소송이 아니라고 본다.

(3) 심판방법

- 전원이 함께하지 않으면 소를 각하해야 한다. 소송절차에서는 1인의 소송행위가 모두에게 이익이 되는 때에만 효력을 발생하며, 판결은 반드시 전원에 대하여 동일하게 선고되어야 한다.

3. 유사필수적 공동소송

(1) 의의

- 공동소송인 각자가 단독으로 소를 제기할 권능이 있으나, 판결의 효력이 제3자에게 확장되는 결과 재판의 모순을 피하기 위해 합일확정이 강제되는 경우이다.

(2) 인정 여부

- 주주총회결의취소의 소에서 여러 주주가 공동으로 제소하는 경우 등이 대표적이다.

(3) 심판방법

- 소송요건은 개별적으로 갖추어도 무방하나, 일단 공동소송이 성립하면 소송자료와 소송진행이 통일되어야 한다. 1인의 상소는 전원에 대하여 효력이 발생한다.

IV. 예비적 · 선택적 공동소송

1. 의의

(1) 개념[민소법 제70조]

- 공동소송인들 중 누구의 청구가 인용될지 불분명하거나, 누구에 대한 청구가 인정될지 불확실한 경우에 대비하여 서열을 붙여 청구하거나(예비적), 선택적으로 청구하는 형태를 말한다.

(2) 인정취지

- 피고를 누구로 할지, 혹은 원고 중 누가 청구권을 가졌는지 법률적으로 모호할 때 한꺼번에 소를 제기하여 판결의 모순을 막고 당사자의 구제를 도모하기 위함이다.

2. 소송의 유형

(1) 수동형과 능동형

- 여러 명의 피고를 상대로 하는 경우를 수동형, 여러 명의 원고가 참여하는 경우를 능동형이라 한다.

(2) 예비형과 선택형

- 주위적 피고와 예비적 피고를 구분하는 것이 예비형이며, 순위 없이 어느 한 명에 대해서만 청구가 인용되기를 구하는 것이 선택형이다.

(3) 원시형과 후발형

- 소 제기 당시부터 병합하는 것이 원시형이며, 소송 도중에 피고를 추가하는 방식 등이 후발형이다.

3. 요건

(1) 법률상 양립 불가능

- 예비적 · 선택적 공동소송이 허용되기 위해서는 당사자들 사이의 권리 · 의무가 법률상 서로 양립할 수 없는 관계에 있어야 한다. 즉, A에 대한 청구가 인용되면 B에 대한 청구는 반드시 기각되어야 하는 관계여야 한다.

(2) 공동소송인의 일반요건

- 민사소송법 제65조의 요건을 갖추어야 하며, 주위적 청구와 예비적 청구 사이의 관련성이 인정되어야 한다.

4. 심판방법

(1) 소송요건의 심사

- 공동소송인 전원에 대해 개별적으로 소송요건을 심사한다.

(2) 소송자료의 통일

- 필수적 공동소송에 관한 규정이 준용되므로 소송자료가 통일되어야 한다. 1인의 자백은 다른 이에게 불이익하다면 효력이 없다.

(3) 소송진행의 통일

- 변론과 판결은 반드시 동시에 행해져야 하며, 일부판결은 허용되지 않는다.

(4) 본안재판의 통일

- 법원은 양립 불가능한 청구들에 대해 모순 없는 판단을 내려야 한다. 주위적 청구를 인용하면 예비적 청구에 대해서는 판단할 필요가 없으나, 주위적 청구를 기각할 때는 반드시 예비적 청구에 대해 판단해야 한다.

(5) 상소심에서의 소송진행의 통일

- 일부 당사자에 대한 판결에 대해서만 상소가 제기되더라도 사건 전체가 상소심으로 이심되며, 상소심 법원은 전 당사자에 대해 다시 심판해야 한다.

V. 추가적 공동소송

1. 의의

- 소송계속 중에 제3자가 공동소송인으로 가입하거나 기존 당사자가 제3자를 끌어들이는 것을 의미한다. 민사소송법상 명문의 규정은 없으나 실무와 학설에서 논의된다.

2. 해석상 추가적 · 주관적 공동소송 인정 여부

(1) 학설

- 긍정설은 소송경제와 분쟁의 일회적 해결을 근거로 허용하자는 입장이고, 부정설은 절차의 복잡화와 상대방의 방어권 침해를 이유로 반대한다.

(2) 판례

- 대법원은 원칙적으로 민사소송법이 허용하는 예외적인 경우(제68조 필수적 공동소송인 추가 등)를 제외하고는 일반적인 추가적 공동소송을 부정하는 태도를 취하고 있다.

(3) 검토

- 피고의 동의가 있거나 소송의 기초를 변경하지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용하는 것이 타당하나, 현행법 체계상 명확한 근거가 부족하므로 입법적 해결이 필요하다.

VI. 선정당사자

1. 의의[민소법 제53조]

(1) 개념

- 공동의 이해관계를 가진 여러 사람이 그들 중에서 모두를 위하여 소송을 수행할 1인 또는 여러 명을 선임하는 제도이다. 선정된 자를 선정당사자, 선정한 자를 선정자라고 한다.

(2) 인정취지

- 다수당사자가 관여하는 소송에서 절차의 복잡성을 피하고 소송을 원활하게 진행하기 위함이다.

2. 요건[민소법 제65조]

(1) 공동소송을 할 여러 사람이 있을 것

- 민사소송법 제65조 전단의 요건을 갖춘 다수인이 존재해야 한다.

(2) 공동의 이해관계가 있을 것

- 소송목적인 권리·의무가 공통되거나 사실상·법률상 주요한 원인을 같이하여 재판의 결과에 대해 이해를 같이해야 한다.

(3) 공동의 이해관계가 있는 자 중에서 선정할 것

- 선정당사자는 반드시 선정자 그룹의 일원이어야 한다. 제3자를 선정하는 것은 허용되지 않는다.

3. 선정의 방법

(1) 의의

- 선정은 소송계속 전후를 불문하고 할 수 있으며, 서면으로 증명해야 한다.

(2) 선정의 성질

- 선정은 일종의 소송상 신임관계로, 대리권의 수여와는 성격이 다르다. 선정당사자는 자신의 이름으로 소송을 수행하는 당사자 본인이 된다.

4. 선정의 효과

(1) 선정당사자의 지위

- 소송수행권을 독점하며, 모든 소송행위를 할 수 있다. 판결의 결과는 선정자 모두에게 미친다.

(2) 선정자의 지위

- 선정자는 소송에서 탈퇴하게 되며, 별도로 소송에 관여할 수 없다. 다만, 선정당사자의 자격이 상실되면 다시 소송에 복귀할 수 있다.

5. 선정당사자의 자격흡결의 효과

(1) 소송요건

- 선정당사자의 자격은 소송요건이므로 법원은 이를 직권으로 조사해야 한다. 자격이 없는 경우 소를 각하한다.

(2) 간과판결

- 자격 흡결을 간과하고 판결이 확정된 경우, 이는 대리권 없는 자에 의한 소송수행과 유사하게 취급되어 재심사유가 될 수 있다.

6. 선정당사자의 기타 논점

(1) 공동의 이해관계가 없는 선정당사자가 인낙한 인낙조서에 대한 재심 가부

- 공동의 이해관계가 없음에도 선정당사자로 선임되어 행한 인낙은 무효이며, 이에 기초한 인낙조서에 대해서는 준재심의 소를 제기할 수 있다는 것이 판례의 입장이다.

(2) 선정당사자의 부재소합의

- 선정당사자가 선정자들을 대표하여 행한 부재소합의는 그 효력이 선정자 전원에게 미친다.

(3) 선정당사자의 자격상실

- 선정당사자가 사망하거나 사임하면 자격이 상실된다. 이때 다른 선정당사자가 있다면 그가 소송을 수행하고, 없으면 소송절차는 중단된다.

VI. 결론

- 공동소송 제도는 다수의 당사자가 얽힌 복잡한 법률관계를 하나의 사법 절차 안에서 효율적으로 해결하기 위한 필수적 장치이다. 특히, 통상공동소송과 필수적 공동소송의 구별은 당사자의 소송 수행 자유와 재판의 합일확정이라는 가치 사이의 균형점을 찾는 과정이다. 현대 소송에서는 집단적 분쟁이 증가함에 따라 예비적·선택적 공동소송과 선정당사자 제도의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이러한 제도들은 소송절차의 명확성을 확보하고 판결의 모순을 방지함으로써 사법 신뢰를 공고히 하는 데 기여한다. 향후 추가적 공동소송의 광범위한 허용 여부 등 입법적 보완을 통해 다수당사자 소송의 효율성을 더욱 극대화할 필요가 있다.